

Expediente Nº: TD/00264/2019
1037-100919

RESOLUCIÓN Nº: R/00623/2019

Visto el recurso de reposición dictado por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos por el que se impugna la Resolución de esta Agencia con número de referencia E/08874/2018 de fecha 9 de enero de 2019 por acuerdo de no admisión a trámite de la reclamación presentada por D. **A.A.A.**, frente a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U., por la desatención del ejercicio de acceso

Realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el Título VIII de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD), se han constatado los siguientes

HECHOS

PRIMERO: **A.A.A.** (en adelante, la parte reclamante) ejerció derecho de acceso frente a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U. con NIF **A78923125** (en adelante, la reclamada), sin que su solicitud haya recibido la contestación legalmente establecida.

La parte reclamante aporta diversa documentación relativa a la reclamación planteada ante esta Agencia y sobre el ejercicio del derecho ejercitado y señala que, con motivo de una reclamación derivada de la relación contractual, ejercita el derecho de acceso ante la reclamada a través de distintos canales de comunicación, entre ellos por vía telefónica (1004), a través del foro de la comunidad de Movistar, y por último mediante el envío de un correo electrónico a la dirección "escribenos@telefonica.com", en fecha 20/09/2018, en el que solicitaba copia de la grabación telefónica de la contratación de celebración del contrato "Movistar Fusión" con fecha de inicio el 13/06/2018.

SEGUNDO: En fecha 23 de enero de 2019, el recurrente presenta un escrito en la Oficina de Correos de Girona, que es registrado en la AEPD en fecha 28 de enero de 2019, mediante el cual interpone un recurso potestativo de reposición contra la resolución recaída en el expediente E/08874/2018, en el que muestra su disconformidad con la resolución impugnada, argumentando que la entidad reclamada no le ha facilitado el acceso a la grabación solicitada.

TERCERO: Con fecha 3 de septiembre de 2019, ésta Agencia a través del Soporte del Servicio de Notificaciones Electrónicas y Dirección Habilitada (plataforma Notific@), puso a disposición del responsable del tratamiento la reclamación presentada por la parte reclamante y con fecha 9 de septiembre de 2019 el responsable del tratamiento acepta la Notificación Electrónica, para que en el plazo de quince días se remita a esta Agencia las alegaciones que consideren convenientes, por lo que se realizaron, en síntesis, las siguientes alegaciones:

- ✓ La reclamada manifiesta en las alegaciones formuladas durante la tramitación del presente procedimiento y recoge argumentos relacionados con la reclamación derivada de la relación contractual con el interesado y durante la tramitación de este procedimiento señala que, no se dispone de grabación fechada el 13 de junio de 2018.
- ✓ Con fecha 27 de septiembre de 2019, ésta Agencia a través del Soporte de Notificación por medio de la Carpeta ciudadana, puso a disposición de la parte reclamante las alegaciones presentadas por el responsable y con la misma la parte reclamante accede a la Notificación Electrónica, para que en el plazo de quince días se remitan a esta Agencia las alegaciones que consideren convenientes, sin haber recibido respuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 56 en relación con el apartado 1 f) del artículo 57, ambos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo, RGPD); y en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD).

SEGUNDO: El artículo 64.1 de la LOPDGDD, dispone lo siguiente:

“1. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se adoptará conforme a lo establecido en el artículo siguiente.

En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación.”

TERCERO: El artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD), dispone que:

“1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22. En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado.

3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:

a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o

b) negarse a actuar respecto de la solicitud.

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.

7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos 13 y 14 podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato electrónico serán legibles mecánicamente.

8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 92 a fin de especificar la información que se ha de presentar a través de iconos y los procedimientos para proporcionar iconos normalizados.”

CUARTO: El artículo 15 del RGPD dispone que:

“1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:

- a) los fines del tratamiento;
- b) las categorías de datos personales de que se trate;
- c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales;
- d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
- e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
- f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
- g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;
- h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.

3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.

4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.”

QUINTO: El artículo 13 de la LOPDGDD determina lo siguiente:

“1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.

Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.

2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales

efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.

No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto.

3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.

4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.”

SEXTO: Los apartados 1) y 2) del artículo 4 del RGPD, que trata sobre las definiciones, señalan:

“1) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;

2) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;”

SÉPTIMO: Antes de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, hay que señalar que el presente procedimiento se instruye como consecuencia de la denegación de alguno de los derechos regulados por la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición) y tiene por objeto que se adopten las medidas correspondientes para que las garantías y derechos del afectado queden debidamente restauradas. Por ello, en el presente caso, sólo serán analizadas y valoradas aquellas cuestiones planteadas por la parte reclamante que queden incluidas dentro del objeto del citado procedimiento de reclamaciones en materia de protección de datos.

Con respecto a si procede o no el acceso solicitado, hay que señalar que, conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del art. 4 del RGPD anteriormente transcrito, la voz se considera como dato personal. Por ello, en principio, la parte reclamante tendría derecho a que se le facilitasen esas grabaciones, al amparo de la normativa de protección de datos. Sin embargo, dichas grabaciones pueden contener, además de sus datos, información relativa a terceras personas que no le podría ser comunicada, ya que, en caso contrario, podría constituir una cesión de datos sin consentimiento.

En este sentido, se ha de considerar que la voz es una característica peculiar e individual de cada persona que la hace identificable, por lo tanto, es un dato de carácter personal. En consecuencia, el derecho de acceso a la grabación de su voz solicitado por la parte reclamante sí está amparado por la normativa vigente en materia de protección de datos, facilitando la copia de la grabación solicitada a la parte reclamante o, en su defecto, transcripción de su contenido.

Dicho lo anterior, en el supuesto aquí analizado, la parte reclamante ejercitó su derecho de acceso a las grabaciones de voz con objeto de la celebración del contrato “Movistar Fusión” de fecha 13/06/2018, y que, transcurrido el plazo establecido conforme a las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible, dado que no se facilitó el acceso requerido ni se denegó motivadamente.

Por otro lado, durante la tramitación del presente procedimiento, la entidad ha contestado al derecho de acceso solicitado, donde señala que no dispone de la grabación solicitada, siendo dicha alegación objeto de traslado a la parte reclamante, mediante escrito de salida de fecha 27 de septiembre de 2019 a través del Soporte de Notificación por medio de la Carpeta ciudadana, sin que haya presentado alegación alguna frente al mismo.

Conforme a lo establecido en el art. 98 del Real Decreto Legislativo 1/2007, recoge que, los contratos celebrados por teléfono son legales, pero exige su ratificación por escrito o por otro soporte duradero y solo quedara vinculado una vez que se haya aceptado la oferta mediante firma o mediante el envío de aceptación por escrito.

Por ello, esta Agencia sólo tiene competencia sobre los datos personales, sin que se pueda valorar la información concerniente a posibles contratos suscritos o incidencias sobre los mismos, ni dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la correcta prestación de los servicios contratados o la interpretación de cláusulas contractuales con independencia de que otra normativa ampare la obtención de dicha información, como son, entre otros, el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1993, sobre condiciones generales de contratación.

La determinación de las condiciones de la prestación contractual o comercial, basada en una interpretación del contrato suscrito entre las partes y de su correcta aplicación, deberá instarse ante los órganos administrativos o judiciales competentes, al exceder del ámbito competencial de la Agencia.

Entre los órganos que dictan resoluciones vinculantes a esos efectos figuran las Juntas Arbitrales de Consumo (siempre que el acreedor voluntariamente se someta a ellas), la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (www.usuarioteleco.gob.es) o los órganos judiciales. No resultan vinculantes, entre otras, las decisiones de las organizaciones de consumidores ni de las oficinas municipales de consumo.

Por consiguiente, procede estimar por motivos formales la presente reclamación al haberse emitido la respuesta extemporáneamente sin que se requiera la realización de actuaciones adicionales por parte del responsable del fichero.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos **RESUELVE:**

PRIMERO: ESTIMAR por motivos formales, la reclamación formulada por D. **A.A.A.**, contra la entidad TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U. No obstante, no procede la emisión de nueva certificación por parte de dicha entidad, al haberse emitido la respuesta extemporáneamente, sin que se requiera la realización de actuaciones adicionales por parte del responsable.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. **A.A.A.** y a TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U..

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos